

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

3VAFAZPUB

3ª Vara da Fazenda Pública do DF

Número do processo: 0701747-49.2022.8.07.0018

Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias (5946)

IMPETRANTE: TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA.

IMPETRADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de **Mandado de Segurança** com **pedido de liminar** impetrado por **TÊXTEL MN COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA** contra ato, em tese, praticado pelos **Ilmo. Sr. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA** e **Sr. SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL**, buscando, liminarmente: **a)** suspender a exigibilidade dos créditos tributários de DIFAL, no período compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL; **b)** abstenção de qualquer penalidade ou sanção, exclusivamente em razão dos valores do DIFAL, impedindo o impetrado de: apreender mercadorias; lavrar auto de infração para exigir os valores; inscrever valores em conta corrente fiscal, bem como CADIN, SPC, SERASA, lista de devedores da Procuradoria ou qualquer outro cadastro restritivo; inscrever valores em Dívida Ativa do Estado ou levá-los a protesto; exigir os valores, abarcados por liminar, por meio de execução fiscal; negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal ou certidão positiva com efeitos de negativa; cancelar inscrições estaduais e revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais à Impetrante.

Relata ser pessoa jurídica de direito privado e que, no exercício de suas atividades, efetuando a venda de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS, sujeita ao pagamento do ICMS-DIFAL situados no Distrito Federal.

Indica que através do julgamento do RE 1.287.019 e ADI n. 5.464, representativos do Tema n. 1.093 do STF, a Colenda Corte decidiu que a ausência de lei complementar torna a exigência do ICMS Difal indevida, tendo modulado os efeitos da decisão.

Descreve que referida tese foi vinculada, tendo os seus efeitos protraídos para o ano de 2022, motivo pelo qual em janeiro de 2022 foi publicada a Lei complementar n. 190/2022. No seu entendimento, referida Lei deve se submeter a anterioridade nonagesimal, de modo que a cobrança imediata do ICMS Difal se mostra indevida.

Requer o deferimento de medida liminar nos termos acima alinhavados e, no mérito, a sua confirmação para reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários do DIFAL, no período compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, declarando o direito à restituição dos valores porventura indevidamente recolhidos, devidamente atualizados, o que poderá se dar à escolha da Impetrante pela expedição de precatório, recomposição de sua escrita fiscal, compensação (Súmula 213/STJ) ou restituição os valores recolhidos indevidamente, podendo, em caso de compensação, ser compensado os valores com quaisquer tributos e/ou contribuições vencidos e/ou vincendos administrados pelo Estado, atualizados monetariamente pela taxa Selic e as demais cominações moratórias incidentes sobre o principal, desde a data de cada pagamento indevido.

Dá à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Custas

recolhidas

(ID

116404069

(<https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?>

[id=2587695&ca=65949d81994d66aa55657f53287e51c7e9d88dbadae8826e9724b798a43973171e19daad63bb909f4c2a64922bc35ddf9ccef146623d6](https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?ca=65949d81994d66aa55657f53287e51c7e9d88dbadae8826e9724b798a43973171e19daad63bb909f4c2a64922bc35ddf9ccef146623d6)

Os autos vieram conclusos para decisão.

É O RELATO. DECIDO.

Passo a verificar se presentes os requisitos para a concessão do pedido de liminar.

A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e de reconhecimento pela espera de que a regular tramitação da ação será danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

No caso dos autos, a parte impetrante busca a suspensão da exigibilidade do ICMS Difal, sustentando, em síntese, que após a Decisão da Suprema Corte no Tema n. 1.093 foi pacificado o entendimento segundo o qual a cobrança do ICMS Difal exige a prévia edição de Lei Complementar. Além disso, defende que a cobrança de imposto exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Observa-se, de fato, que o colendo STF, no Tema da Repercussão Geral n. 1.093, fixou tese no sentido de que a cobrança do ICMS Difal pressupõe a edição de lei complementar, a saber:

"Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. (...) Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)."

No referido julgamento foi reconhecida a inconstitucionalidade do Difal justamente pela ausência de lei complementar.

Na modulação dos efeitos, o STF considerou que a inexigibilidade do Difal somente seria concretizada a partir de janeiro de 2022, tendo ressaltado apenas as ações em curso, no momento da decisão.

(...) Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderiu à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)."

Confira-se o teor da ementa do citado julgamento:

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b).

Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i). 4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. **5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispoendo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.** 6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. **11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),** exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. **Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.** (STF - ADI: 5469 DF 0001144-61.2016.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021).

Nessa perspectiva, em princípio, entende-se que a lei complementar sobre o ICMS Difal deveria ter sido instituída ainda no ano de 2021, viabilizando a sua produção de efeitos a partir de 2022, sob pena de os Estados serem obstados da cobrança do citado do tributo no atual exercício financeiro, consoante decidido pelo colendo STF no Tema n. 1.093.

A análise do tema permite perceber que foi implementada a Lei Complementar n.º 190/2022, cujo conteúdo regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Contudo, referida Lei apenas foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022[1] (file:///C:/Users/pc/Documents/Carol/Difal/DECIS%C3%83O%20-%20DIFAL%20-%20LIMINAR%20-%20FEV%202022%20-%200701747-49.docx#_ftn1), a indicar, nesse juízo inicial, a inobservância da anterioridade anual caso o tributo em questão seja cobrado no ano de 2022.

Ademais, percebe-se que a Lei Complementar n.º 190/2022 dispõe que a produção dos seus efeitos pressupõe a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, o que significa dizer, em princípio, que no prazo de 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei não haverá a cobrando do ICMS Difal. Confira-se:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Não obstante referida previsão, constata-se que foi editado recentemente Convênio Confaz, por meio do qual foi prevista a cobrança do ICMS Difal, estabelecendo-se a produção de efeitos a partir de janeiro de 2022, a indicar a existência de efetivo perigo de dano.

Assim, o pedido liminar deve prosperar.

Forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO A LIMINAR para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal durante o exercício de 2022, até julgamento da demanda.

Determino à autoridade coatora abstenha de aplicar à parte impetrante qualquer tipo de sanção ou medida restritiva de direitos, **exclusivamente em razão dos valores do Difal**, em decorrência de seu não recolhimento até o julgamento de mérito da presente mandamental.

Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09.

Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09.

Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1ª a 4ª), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato.

Após, ao Ministério Público.

Concedo a essa decisão força de mandado.

Intimem-se.

Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2022 13:48:46.

JANSEN FIALHO DE ALMEIDA

Juiz de Direito

[1] (file:///C:/Users/pc/Documents/Carol/Difal/DECIS%C3%83O%20-%20DIFAL%20-%20LIMINAR%20-%20FEV%202022%20-%200701747-49.docx#_ftnref1) Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp190.htm>. Acesso em 21/1/2022

Assinado eletronicamente por: JANSSEN FIALHO DE ALMEIDA

22/02/2022 14:03:37

https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

ID do documento: 116449874



22022214033757500000108100249

IMPRIMIR

GERAR PDF